

1501760-34.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501760-34.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501760-34.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245023/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 20131153 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1171/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2245023 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIKE SANTIAGO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

VISTOS.

KAIQUE SANTIAGO DE SOUZA, já qualificado, foi denunciado como incurso no art.33 "caput" c.c.art.40, inciso III da lei 11.343/06.

Apresentada a defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.152 ss.) e laudo químico toxicológico (fls.118 ss.).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa e o réu foi interrogado (fls.155 ss.).
As partes se manifestaram em alegações finais (fls.155/156 e fls.158 ss.).

É o relatório.

DECIDO.

Em que pesem as ponderações da ilustre e combativa Defesa, a ação penal é procedente.

Os policiais civis ouvidos em juízo disseram que o local já é conhecido como sendo ponto de venda de drogas há anos; no dia dos fatos foram ao local em razão de uma denúncia anônima e fizeram uma breve campana durante a qual eles observaram o réu, o qual se encontrava próximo a um vaso de plantas; viram quando um suposto comprador se aproximou dele e ele buscou algo atrás do vaso e entregou ao suposto comprador; em razão da conduta típica de venda de drogas, procederam à abordagem. Com o réu encontraram a quantia de R\$ 28,00 em dinheiro. Atrás do vaso de plantas que eles observaram encontraram as drogas em uma sacola. O réu admitiu os fatos informalmente. Não mais se recordaram se o réu mencionou ser usuário, ou se aparentava estar drogado. Não conheciam o réu anteriormente e o local fica próximo a escolas.

A testemunha de defesa ouvida disse que é terapeuta e que o réu é dependente químico e usa vários tipos de entorpecentes há anos e tratou do acusado por alguns meses; no início do tratamento o réu sequer sabia o que acontecia. Disse que nunca soube de nenhum envolvimento do réu com a criminalidade e que ele vem de família religiosa e estruturada e que trabalhava, mas perdeu o emprego por conta do vício. O réu, ao ser interrogado, negou os fatos; afirmou ser usuário de entorpecentes e disse que foi até o local com o intuito de adquirir cocaína para o seu uso. Afirmou que tinha consigo R\$ 58,00 para aquisição da droga; costumava comprar naquela biqueira, pois mora ali perto. Mora com os pais e não tem outras passagens. Portanto, não obstante as alegações do réu, restam dúvidas quanto à autoria. O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266).

Ressalta-se que os depoimentos dos agentes da lei não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrente.

Este é o entendimento adotado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que

esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus nº 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.18.2.97). No mesmo diapasão já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min.MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011). "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório" (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5ª Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

Outrossim, não há porque duvidar destes depoimentos que estão em sintonia com as demais provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles tenham sido mentiras ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.

Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

Portanto, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente, de modo que os depoimentos podem e devem ser utilizados como meio de prova.

O fato do réu ser eventualmente usuário de drogas é irrelevante no caso.

De fato, há de se ponderar que a condição de dependente não exclui, por si só, a condição de traficante, sendo possível a coexistência das características de traficante e viciado. Neste sentido farta jurisprudência (RT 736/712; RJTJSP 101/498; 84/382; RJTJSR 179/152).

Ademais, é comum que o narcotráfico faça uso justamente dos dependentes químicos para realização da venda dos entorpecentes, eis que eles, assim, conseguem sustentar o seu vício.

A materialidade vem evidenciada pelo laudo químico toxicológico de fls.118 ss. e pelos demais autos de apreensão juntados aos autos.

Há de ser reconhecida, por outro lado, a causa de aumento prevista no art.40, inciso III da lei 11.343/06, já que o crime foi praticado nas proximidades de escolas.

O réu é primário, de sorte que faz jus à pena em seu mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão, os quais deverão ser cumpridos em regime fechado, a teor do que estatui o art.33§3º do Código Penal e considerando a gravidade do delito, equiparado ao crime hediondo, verdadeiro flagelo social. Considerando a causa de aumento imputada na denúncia, aumento a pena em 1/6, num total de 05 anos e 10 meses de reclusão, os quais deverão ser cumpridos em regime fechado.

Deixo de diminuir as penas nos termos do que dispõe o art.33§4º da lei 11.343/06, visto que os réus não preenchem os requisitos necessários. É evidente que o réu faz parte de organização criminosa. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode ser dissociada da atividade de uma organização criminosa. Ora, há sempre a grande organização criminosa que adquire e distribui a droga, que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores.

O réu não poderia agir sozinho, dissociado de uma rede muito bem organizada e articulada.

Aliás, neste sentido se posiciona a Jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16 quilos de maconha, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V - Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 495838 MS 2019/0059322-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).

HABEAS CORPUS Nº 495.838 - MS (2019/0059322-5) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANDRA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS - MS004313 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PACIENTE : ANTONIO MARCIO AVELINO (PRESO) EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores

decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no Resp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16 quilos de maconha, elemento Documento: 1840691 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/06/2019 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V - Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Brasília (DF), 18 de junho de 2019(Data do Julgamento) Ministro Felix Fischer Relator

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado, de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. 5. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, que restou evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. (...) (STJ. HC 427339 RJ 2017/0313649-4. T5 - QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julg. 27/08/2018. DJe 08/03/2018) Grifos não contidos no original.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA DE ALTO PODER DESTRUTIVO E QUANTIDADE RAZOÁVEL. BENESSE NÃO APLICADA. (...) 3. A natureza da substância entorpecente de alto poder destrutivo e a relevante quantidade psicotrópicos apreendida obstam a incidência da minorante do tráfico privilegiado. (TJ-AM. 00004617220178045600 AM 0000461-72.2017.8.04.5600. Primeira Câmara Criminal. Rel. Carla Maria Santos dos Reis. Julg. 14/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRECEDENTES DO STF E STJ - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA UM DIVERSO DO FECHADO - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDEM A MODIFICAÇÃO - ENUNCIADO Nº. 47 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 2. Sendo constatada considerável quantidade de

droga apreendida, e tendo o magistrado sentenciante se utilizado desses vetores para não aplicar o tráfico privilegiado, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MT. Ap 18857/2018. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. Julg. em 12/09/2018. Pub. no DJE 21/09/2018) Grifos não contidos no original.

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1035945/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas” AgRg no AREsp 1293358/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/5/2019).” (HC 511.370/RJ, j. 04/06/2019)

O réu pode ser considerado pessoa pobre na acepção jurídica do termo, assim, fixo-lhe a pena pecuniária em 500 dias-multa, no mínimo legal. Considerando a causa de aumento imputada na denúncia, aumento, também, a pena pecuniária em 1/6, num total de 583 dias multa-no mínimo legal.

Praticou ele crime grave, daqueles que causam intranquilidade e comoção social, equiparado ao hediondo, motivo pelo qual persistem os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal, não fazendo ele jus à liberdade provisória.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno, KAIQUE SANTIAGO DE SOUZA, já qualificado, a 05 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art.33 “caput” c.c.art.44, inciso III da lei 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lancem o seu nome no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA